

1500663-75.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... recebido denúncias de que ocorria tráfico no local, mas não era local marcado pelo tráfico. Populares às vezes paravam o depoente ou outros policiais, informando sobre a ocorrência da traficância há algum tempo. No caso, populares não quiseram se identificar por temer represália e informaram que na casa do numeral 418 havia tráfico e prostituição e que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500663-75.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500663-75.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098218/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 24206390 -

DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2098218 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu

VINICIUS FELIX DE MENDONÇA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

VINICIUS FÉLIX DE MENDONÇA RIBEIRO (fls. 15) foi denunciado como incurso no art.

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (fls. 1/3).

Isso porque, segundo consta, em 10 de abril de 2022, por volta das 00h30m, na Rua Manoel da Silva Oliveira, 418, Jardim das Flores, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de comércio, 41,65 gramas de cocaína e 3,6 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, apreendidas a fls. 20/21 e periciadas a fls. 72/74.

Consta também que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, em seu local de trabalho, uma pistola Taurus, calibre 380, de uso permitido, contendo um carregador municiado com 08 cartuchos íntegros, apreendidos a fls. 17/18, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Paulo Henrique Modonese Costa

(fls. 5) e PM Carlos Alberto Abel Pereira (fls. 6).

O acusado foi notificado (fl. 128), citado pessoalmente (fls. 161) e apresentou defesa prévia (fls. 95/116), por defensor constituído (fls. 59), negando a prática do delito, pedindo absolvição e arrolando as mesmas testemunhas de Acusação e as seguintes testemunhas de Defesa: Pollyana de Cassia Torres Rodrigues, Sara Regina da Silva; Nadhabia Paola Ferreira; Cicera Luisa de Sousa Lima

Recebida a denúncia (fls. 132/134), foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação pelo tráfico nos termos da denúncia e absolvição quanto à acusação de posse ilegal de arma de fogo, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 5/8), auto de apreensão e entrega (fls. 20/21), fotografias (fls. 22/24), documentos (fl. 27/28), relatório (fls. 76/78) e laudos periciais (fls. 29/32; 72/74 e 83/86).

Não há nulidades processuais ou prejuízo à Defesa por não constar na denúncia que foram encontradas drogas no balcão do bar, já que a denúncia descreve que foram localizadas drogas durante "buscas no estabelecimento" e "estavam sendo guardadas pelo denunciado para fins de tráfico", o que é suficiente para permitir o contraditório pelo acusado, sendo questão de mérito analisar se a acusação procede ou não.

No mais, eventuais nulidades do flagrante ficam superadas com o oferecimento da denúncia, valendo lembrar que o acusado, na custódia, foi solto com cautelares.

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Policiais receberam informações de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no bar de propriedade do denunciado. Foram até lá e, durante a abordagem das pessoas que estavam no local, perceberam que o denunciado correu para os fundos e dispensou um objeto. Em busca pessoal, os policiais encontraram um saquinho contendo cocaína. Os policiais identificaram o objeto dispensado pelo denunciado, que se tratava da pistola citada, devidamente municiada. Em seguida, procederam a buscas no estabelecimento e encontraram mais 15 porções de cocaína, bem como uma porção de maconha, as quais estavam sendo guardadas pelo denunciado para fins de tráfico. Embora a arma estivesse registrada em nome do denunciado, ele não tinha autorização para mantê-la em seu estabelecimento comercial.

Foram apreendidos: a quantia de R\$ 43,75 em notas e moedas diversas, 1 pistola Taurus, KLX40491, calibre 380, contendo um carregador, municiado com 8 cartuchos íntegros, contendo ainda 1 cartucho deflagrado; 41,65 gramas de cocaína acondicionada em 16 porções e 3,6 gramas de maconha em 1 papelote.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para:

1- cocaína nas amostras colhidas de 16 invólucros plásticos, sendo 13 invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip") e 03 invólucros fechados por aquecimento, encerrando porção de material sólido particulado com massa líquida de 38,31 grama(s).

2- tetrahidrocannabinol - THC nas amostras colhidas de 1 invólucro plástico do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 1,85 grama(s).

A perícia na arma concluiu que se trata de uma pistola semiautomática usada, da marca Taurus, modelo PT 59, oxidada, de número de série KLX40491, com cano tendo 130 mm de comprimento e 6 raia dextróginas, de carga por carregador, de percussão central, com cão aparente e pino isolado, de uma câmara, de ejeção automática, tendo cabo lateralmente guarnecido por placas de polímero de cor preta. Estava acompanhada de um estojo de cartucho deflagrado e um carregador para pistola da mesma marca, com capacidade para 19 cartuchos, tendo 8 cartuchos instalados no

mesmo. Os 08 cartuchos íntegros contidos no carregador eram da marca CBC, do calibre nominal “.380 AUTO”, com projéteis de chumbo cilindro-ogivais blindados de pontas ocas. O estojo que acompanhava a arma era da mesma marca e calibre, sendo que a munição é compatível com pistolas do calibre “.380” ou similar. Houve percussão da espoleta no estojo examinado.

Não se trata de arma artesanal e não foram constatados vestígios de adulterações nela, sendo que, aparentemente, não tem mecanismos incompletos ou deficientes. Não foram constatados vestígios na arma que indicassem a possibilidade de produzir tiro acidental e a pesquisa de nitrito (pólvora combusta), realizada na arma apresentou resultado negativo. Os ensaios experimentais realizados revelaram sua eficácia, sendo eficiente para produzir disparos. Além disso, testes realizados confirmaram que a munição é eficiente para produzir um tiro, sendo consumidos 03 dos cartuchos examinados.

A testemunha, PM Paulo Henrique Modonese Costa, relatou que tinham recebido denúncias de que ocorria tráfico no local, mas não era local marcado pelo tráfico. Populares às vezes paravam o depoente ou outros policiais, informando sobre a ocorrência da traficância há algum tempo. No caso, populares não quiseram se identificar por temer represália e informaram que na casa do numeral 418 havia tráfico e prostituição e que o proprietário portava arma de fogo. O transeunte pediu sigilo e por isso seria leviano apresentar características físicas, mas se tratava de indivíduo do sexo masculino, por volta de 30 anos e estatura mediana. Devido à quantidade de pessoas no local, foi acionado o comando força e todos os presentes foram submetidos a busca pessoal e qualificação, mas alguns indivíduos correram para o fundo do bar. Ali existia um terreno com área de terras e árvores. Nesse momento as equipes se dividiram para alcançá-los. O Sargento Abel e o Tenente Viana correram para o fundo e ali alguns conseguiram pular o muro para se evadir. Com as pessoas abordadas pelo depoente nada de ilícito foi encontrada. Na busca pelo balcão, onde se encontravam doces e balas, o depoente localizou, em meio aos chicletes e balas, porções que aparentavam ser cocaína. Foram localizadas 11 porções embaladas de forma idêntica e outras porções embaladas de forma diferente e outras porções de maconha, todas localizadas na parte do caixa. Ao se deslocar ao fundo do bar, foi informado que um indivíduo, o acusado, tinha sido localizado com uma porção idêntica de cocaína à que tinha sido encontrada. O acusado afirmou que a droga consigo era destinada para consumo pessoal e negou tráfico no bar. Com o acusado estava com pistola calibre 380 Tauros, que dispensou entre as folhagens, visando escondê-la. Ele estava com porte ilegal de arma de fogo de uso permitido porque não tinha guia de trânsito para portar a arma no local, ou seja, o local era impróprio. O CR, registro da arma, foi apresentado posteriormente. Foi localizada pequena quantia em dinheiro no bar. Não chamaram pessoas para acompanhar as buscas e o acusado não acompanhou as buscas na frente do bar. Tudo ocorreu de forma concomitante.

A testemunha PM Carlos Alberto Abel Pereira narrou que após a busca pessoal foi até o fundo do imóvel. Localizou a pistola embaixo de uma folha de bananeira. No bolso da calça do acusado foi encontrada a porção de cocaína. Demais porções foram localizadas pelo PM Costa. O depoente seguiu pelo fundo. As atuações das equipes foram concomitantes. Durante o patrulhamento no Jardim das Flores, transeunte solicitou a viatura para relatar que havia tráfico de drogas no bar e prostituição e o proprietário possuía a arma de fogo. O acusado afirmou que a droga era para uso pessoal. O depoente não pode afirmar que era para uso do acusado porque as porções de cocaína estavam acondicionadas da mesma forma, todas do mesmo jeito. Não acompanhou a busca pessoal nos demais. Eram várias pessoas no bar. Havia um quartinho com colchão no chão e roupas ali, não sabe se pertencentes ao acusado. No dia, em pesquisa, não foi localizado o registro da arma. No bar foi localizada quantia em torno de R\$ 40,00. Apenas o acusado correu para o fundo do bar.

A testemunha Sara Regina da Silva relatou que estava sentada na pracinha quando viu as viaturas chegando e todo mundo que estava de fora correu pro fundo. Ali havia cerca de 10 mesas e pessoas em pé conversando, como na sinuca, então havia cerca de 40 pessoas no bar. Começaram a chamar o pessoal lá fora para revistar e ficaram duas pessoas revistando. Sabe que há clientes do bar que são usuários de drogas e,

até onde sabe, não ocorria tráfico ali. Precisou pagar a conta depois.

A testemunha Pollyana de Cassia Torres Rodrigues afirmou que estava perto do balcão e o acusado teve um atrito com um homem de porte médio moreno, que não queria pagar a conta. Depois desse desentendimento, os policiais foram fiscalizar o bar. Na praça de frente há vários usuários, mas no bar nunca viu tráfico. O acusado estava no salão do lado, onde fica uma mesa de sinuca. No momento da abordagem, todo mundo correu para dentro e a maioria correu para o fundo do bar. A depoente não sabe para onde o acusado foi. Pediram para aguardar do lado de fora e não acompanhou as buscas.

Houve desistência das demais testemunhas.

Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, afirmando que o bar é grande e consegue acomodar cerca de 100 pessoas. O interrogando estava ali há pouco tempo. Na praça da frente tem muitas pessoas que vão ao bar para usar o banheiro e às vezes tinha desavença com os clientes. No momento da abordagem, não sabia se era assalto e correu junto com os demais. Quando ouviu "polícia", parou e voltou. Na área da horta, várias pessoas tinham pulado o muro. Foi levado para trás do bar e a droga consigo era para consumo pessoal. Não sabe a origem das demais drogas que foram apresentadas. Falou que tinha documento da arma. Os PMs Abel e Paulo não foram os primeiros a chegar. As embalagens das drogas são padrão, como o saquinho de zip-lock. É usuário de cocaína. Não acompanhou as buscas dentro do bar. É um bar de livre acesso. A arma estava guardada no quarto, e não embaixo da folha de bananeira. Morava no bar e ali é sua residência, podendo estar na posse da arma ali.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito de tráfico está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Os policiais estavam em patrulhamento, quando receberam "denúncia" de popular de que um indivíduo estaria comercializando drogas em um bar, no bairro Jd. Das Flores, local descrito outras vezes como ponto de tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, abordaram as pessoas que ali estavam, sem encontrar nada de ilícito com elas, no entanto perceberam o acusado correndo para os fundos e, na revista pessoal no denunciado, foi localizado um saquinho com cocaína. Em paralelo, durante as buscas no estabelecimento, os policiais localizaram no balcão do bar, em meio a chicletes e balas, mais 15 porções de cocaína e uma porção de maconha, que estavam sendo armazenadas pelo acusado.

Pela quantidade e pelo local onde foram encontradas (ou seja, para além do bolso da calça do acusado, no balcão do bar, onde há venda de balas, doces etc., isto é, troca de mercadoria por dinheiro), não é possível afirmar de plano que elas se destinavam apenas a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o horário (madrugada) e a quantidade de pessoas no bar (várias) deixam claro que o réu guardava o entorpecente com o objetivo de vendê-lo para o consumo de terceiros, como descrito na denúncia.

Diante disso, perde relevância se parte das drogas era destinada ao consumo pessoal e/ou o motivo pelo qual as embalagens das drogas encontradas com o acusado e no balcão do bar eram idênticas, já que o ponto central, como dito, é que o acusado mantinha as drogas no bar para fins de tráfico.

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas

pretendessem incriminar o acusado falsamente.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexiste presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém (um transeunte ou cliente motivado por desavença) queria prejudicá-lo, colocando as drogas suas no balcão, que seria de livre acesso, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos e considerando ainda que não convence que o acusado simplesmente desconhecia o que tinha ou não tinha no balcão do seu próprio bar no momento dos fatos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de guardar drogas (independentemente de vendê-las ou não), sem autorização, como descrito na denúncia.

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do tráfico.

Por outro lado, não restou cabalmente demonstrado que a quantia encontrada seria produto de venda de drogas, até porque a denúncia qualificou o tráfico na modalidade de guardar drogas e trazê-las consigo, motivo pelo qual ela deve ser restituída ao acusado.

Quanto à posse da arma de fogo, na linha das ponderações do Ministério Público, o local era domicílio do acusado, sobretudo considerando que ali havia um quarto com colchão no chão e roupas, o que afasta a conduta típica. Assim, nesse aspecto, o acusado deve ser absolvido.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede em parte.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo

abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias

judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n.

666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias -multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário (fls. 169/170).

Quanto às demais circunstâncias judiciais (natureza e quantidade de drogas; culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Consequentemente, a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistem indicativos de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor: "Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-

multa.

Logo, torno definitiva a pena em: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pelo montante (inferior a 4 anos), a pena deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483-A das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

I- condenar VINICIUS FÉLIX DE MENDONÇA RIBEIRO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput c. c. art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução; e

II- com fundamento no art. 386, I, do CPP, absolvê-lo da acusação de prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Com o trânsito em julgado, restitua-se ao acusado a arma de fogo e munições apreendidas, bem como os valores apreendidos. Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico. Serve a presente como ofício. Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar. Portanto, ele faz jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos deva ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspensão" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifacio, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA